

1500417-72.2021.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Luis Monteiro Piassi

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Imputação do Crime de Tráfico de Drogas praticado pelo Sr. Lukas Ricardo Furayama Zadi

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

2ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500417-72.2021.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-72.2021.8.26.0605

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2351518/2021 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 22155114 -

DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2351518 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUKAS RICARDO FURAYAMA ZADI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra LUKAS RICARDO FURAYAMA ZADI.

Na denúncia, narra-se que no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 17h15min, na residência situada na Rua Caruaru, nº 163, Apartamento C, Zona Norte, em Ilha Solteira/SP, Lukas Ricardo Furayama Zadi, ouvido e qualificado às fls. 10, guardava, sem autorização legal e regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 1 (uma) porção de substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, com peso bruto aproximado de 49 gramas, e 3 (três) pedras de substância entorpecente popularmente conhecida como crack, derivada da cocaína, com peso bruto aproximado de 18 gramas, de acordo com auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, auto de constatação preliminar de fls. 25/26 e laudos de exames toxicológicos de fls. 104/106 e 107/109.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 72/79).

Os laudos de constatação provisória e definitiva tiveram resultado positivo para cocaína (fls. 25/26, 104/106 e 107/109).

Notificado pessoalmente (fl. 154), o réu ofereceu defesa escrita (fls. 168/170). Recebida a denúncia em 04/07/2022 (fls. 175/176).

No curso da instrução (fls. 228), realizou-se oitiva em audiência de três testemunhas e do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou, no principal, a desclassificação.

Folha de Antecedentes Penais (fls. 193/203) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 204/206, 218 e 219).

É o relatório.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da Imputação do Crime de Tráfico de Drogas praticado pelo Sr. Lukas Ricardo Furayama Zadi

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 núcleos, tratando-se de tipo misto alternativo, ou seja, ainda que o agente pratique mais de um núcleo, a ele será imputado apenas um delito. Além disso, da leitura do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conclui-se que o crime pode restar configurado ainda que a alienação da droga se dê gratuitamente, mas desde que a conduta seja praticada sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ato contínuo de análise do tipo penal, deve-se observar que a lei não exige para a configuração do crime de tráfico a presença de elemento subjetivo especial do tipo, como o faz para o delito de posse de droga para consumo próprio. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, em sua Legislação Criminal Especial Comentada (2021, p. 1.068):

“Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (Dezoito) verbos constantes do art. 33. A propósito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm precedentes no sentido de que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo - o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir).”

No sentido que se vem de expor, veja-se o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial

com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

As substâncias apreendidas foram identificadas pelos peritos como cocaína, definida como droga pelo art. 66 da Lei nº 11.343/2006 e pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

O auto de apreensão (fls. 22/23) e a prova oral produzida em juízo provam que estava na posse do réu.

Em juízo, a testemunha José Adriano, escrivão ad hoc na Polícia Civil, declarou que: foi designado para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu. Durante as buscas na residência, encontrou uma porção de cocaína, uma balança e dinheiro. O réu não estava no imóvel, sendo que sua companheira acompanhou as buscas e declarou que os objetos encontrados pertenciam a Lukas. Outra equipe policial efetuou a prisão do acusado no local de trabalho deste. O réu é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Não testou o funcionamento da balança de precisão.

A testemunha Osmar de Oliveira, Policial Civil, declarou que: foi designado para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do réu. No local, encontraram drogas, balança e dinheiro. O réu estava trabalhando, sendo que sua companheira acompanhou as buscas. Efetuaram a prisão do acusado. Indagado, o réu confessou a traficância, dizendo, porém, que havia deixado de promover a venda de drogas após ter conseguido trabalho. O acusado já foi preso por tráfico de entorpecentes e havia denúncias em seu desfavor. Asseverou que a balança de precisão funcionava perfeitamente e que havia porções de droga "prontas para a venda".

A testemunha Raiany Eudoxia Godoy Campos, ouvida como informante por se amásia do réu, declarou que: acompanhou as buscas na residência. Os entorpecentes foram encontrados em uma cômoda, pertencente a Lukas. Não sabia que havia balança e dinheiro no local, acrescentando que "não mexia nas coisas dele". Já presenciou o acusado sob efeito de drogas. Lukas estava trabalhando no frigorífico há aproximadamente um mês, não sabendo informar se já havia recebido o primeiro salário. Anteriormente, o réu estava desempregado. Estamos juntos há aproximadamente nove anos. Não sabe precisar se o companheiro vendia drogas e quais os tipos de entorpecentes utilizava. O réu foi contratado com salário de aproximadamente R\$ 1.400,00. Na época dos fatos estava desempregada.

O réu Lukas Ricardo Godoy Campos, declarou que: comprou o entorpecente após deixar o emprego na empresa Kebec. Ficou desempregado por aproximadamente dois meses. Tinha a intenção inicial de vender a droga, todavia, conseguiu um novo emprego e,

por isso, desistiu de vendê-la, deixando-a na residência para ir consumindo. É usuário de cocaína e crack. Iria utilizar o entorpecente em aproximadamente 40 dias. Durante o período em que permaneceu desempregado não vendeu drogas. Pagou R\$ 1.200,00 pelo entorpecente. Em relação à balança, disse que “não lembrava” que o objeto estava no local. O dinheiro encontrado era proveniente de sua rescisão trabalhista e de uma pensão que havia recebido. Tentou devolver o entorpecente, mas não conseguiu diante da negativa do traficante.

Em seu interrogatório, o(a) ré(u), narrou que adquiriu e guardou a droga inicialmente com a intenção de vendê-la; contudo, após arrumar emprego, resolveu não mais traficar e guardou a droga para consumo pessoal.

Tenho, portanto, como demonstrado que a droga estava na posse do réu e que se destinava ao consumo de terceiros, ainda que no curso do ação tenha havido alteração do dolo.

Com efeito, na modalidade adquirir e guardar, o crime de tráfico de drogas é formal, de modo que não se exige a posterior comercialização do entorpecente para sua configuração.

Nesta esteira, quando adquiriu e guardou com a intenção de destinar as drogas ao consumo de terceiros, o réu praticou o crime de tráfico de drogas.

No caso, as circunstâncias da ação policial, a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como os apetrechos para o preparo da droga, além dos valores em dinheiro encontrados com o acusado demonstram que era destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico.

Assim, a prova produzida ao longo da instrução criminal, não dá margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, porque angariada com elementos seguros. Não se viu nenhum indício de que evidencie a insinceridade, justifica sua recusa, pelo contrário, representa dados relevantíssimos na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

Anoto ser ponto pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido (HC 461377/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; EDcl no HC 463656/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 24/10/2018).

Por todos, veja-se o seguinte precedente do STF:

“HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do cabimento e processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo Órgão judicante. COMPETÊNCIA – AFERIÇÃO – JUÍZO. A competência há de ser aferida considerado o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA – REPERCUSSÃO – AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a formalização do flagrante não repercute na validade da ação penal. TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.

(HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)”

No mais, como alhures asseverado, o caso, há elementos seguros que demonstram que era destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico e não o de posse de drogas para consumo, razão pela qual afasto o pedido desclassificatório.

Incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que a parte ré praticou a infração penal ora em julgamento após o trânsito em julgado de outra condenação (art. 63 do CP), conforme se extrai da sua Folha de Antecedentes Criminais (fls. 192/203) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 204/206, 218 e 219) e antes do transcurso do lapso depurador (art. 64, inc. I, do CP).

O réu confessou espontaneamente o crime, razão pela qual faz jus à atenuante do art. 65, inc. IV, "d", do CP, na inteligência da Súmula 545 ("Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.") e da Súmula 630 ("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio") ambas dos STJ.

Veja-se que em seu interrogatório o réu disse que guardou as drogas, inicialmente, com a intenção de vender. Cediço que a mudança do dolo, no curso da ação, não altera a consumação do crime. De mais a mais, forçoso reconhecer que nada há nos autos a indicar

Responsabilidade Penal

Tudo bem examinado e ponderado, deve ser observado, ainda nesta sede, que nada alegou a defesa que permitisse afastar a antijuridicidade da conduta delitiva imputada à parte ré, a qual, aliás, agiu com entendimento, autodeterminação e ciência da ilicitude do fato praticado, quando era certamente de se lhe exigir a adoção de conduta diversa.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o Sr. Wellington Flávio Santos Santana praticou o delito de Tráfico de Drogas, devendo ser responsabilizado penalmente pela suas condutas.

III – FIXAÇÃO DA PENA

Dosimetria da Pena do Crime de Tráfico de Drogas praticado pelo Sr. Lukas Ricardo Furayama Zadi.

Em atenção ao Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, inc. XLVI, da CF/88) e ao Sistema Trifásico (art. 68 do CP), passo à dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei 11.343/06), observo que tanto a quantidade quanto a qualidade altamente deletéria das drogas apreendidas recomendam maior reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), tem-se que:

i) Na análise da culpabilidade, deve-se examinar, na lição de Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 788), "(...) a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu". Nada há nos autos que permita concluir por um grau diferenciado de censura da parte ré. Em outras palavras, o grau de censura necessário já é alcançado pelo mínimo da pena aplicada. Assim, a culpabilidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

ii) Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Antes, porém, de proceder a este exame, faz-se oportuno estabelecer alguns parâmetros - à luz da doutrina e da jurisprudência dominantes -, a serem observados.

Segundo Masson, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 416), para a caracterização dos maus antecedentes, "basta a existência de uma condenação penal definitiva", sendo que o "trânsito em julgado da condenação pode ser anterior ou posterior à prática do novo delito". Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é

valorado.

Nesta ordem de ideias, pode ocorrer de a parte ré possuir uma ou mais condenações definitivas por fatos praticados antes do que está sendo atualmente julgado. Cumpre, portanto, estabelecer uma casuística a este respeito.

Em havendo uma única condenação por infração penal anterior, registrada no histórico criminal da parte ré, devem-se distinguir ao menos duas situações: (i) se o trânsito em julgado da condenação pelo fato pretérito for posterior ao fato em julgamento, então estar-se-á diante de um mau antecedente; ou (ii) se tanto o fato pretérito, quanto o trânsito em julgado da condenação a ele relativa, forem anteriores ao fato em julgamento, então estar-se-á diante da reincidência em sentido técnico (art. 63 do CP), salvo se houver transcorrido o prazo depurador (art. 64, inc. I, do CP), hipótese em que a condenação definitiva anterior será valorada como antecedente criminal, observado o sistema da perpetuidade, abaixo examinado.

Em havendo duas ou mais condenações por infrações penais anteriores, registradas no histórico criminal da parte ré, pode ocorrer de: (i) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado (a) após o trânsito em julgado de uma condenação por delito anterior, caso em que essa será valorada como reincidência; e (b) após a prática de outro delito, cujo trânsito em julgado sobreveio antes do julgamento atual, caso em que essa será valorada como mau antecedente; ou (ii) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado após o trânsito em julgado de duas ou mais condenações por delitos anteriores, caso em que uma poderá ser considerada como reincidência e a outra (ou mais) como mau antecedente, observado o entendimento consagrado na Súmula 241 do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial").

Aqui, cabe observar que, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo 1077, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Um resumo do quanto exposto nos é oferecido por Masson (idem, p. 444): "(...) se o réu possui mais de uma condenação definitiva, uma pode ser utilizada como mau antecedente e a outra como agravante genérica (reincidência, não se falando em bis in idem. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, o magistrado deve utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, se for o caso, e as demais como maus antecedentes."

Sobre o momento da condenação penal definitiva utilizada como mau antecedente, vale observar que a ela não se aplica o período depurador de que trata o art. 64, I, do CP, conforme decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, RE 593.818, Tema 150. Em outras palavras, o sistema penal adota a regra da perpetuidade em matéria de antecedentes (nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: 5ª Turma, AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 15/09/2020, DJe. 21/09/2020; e 6ª Turma, AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). Portanto, é possível considerar qualquer condenação anterior (desde que já transitada em julgado e relativa a fato praticado antes daquele atualmente em julgamento), ressalvadas aquelas por atos infracionais pretéritos, pois que não configuram "crime" em sentido estrito (STJ, 5ª Turma, HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe. 12/02/2021; e STJ, 6ª Turma, REsp 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/03/2018, DJe. 14/03/2018).

Por fim, conforme pacífico entendimento do STJ, "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula 636 do STJ), o que, contudo, não afasta a possibilidade de serem eles comprovados por outros meios (STF, 1ª Turma, HC 162.548, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/06/2020, DJe. 03/07/2020; e STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2018, DJe. 24/08/2018). Veda-se, todavia, por força do Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF/88), a utilização de

"inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ).

Postas estas premissas, ao analisar a Folha de Antecedentes Criminais (fls. 193/203) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 204/206) da parte ré, constata-se a existência de mais de uma condenação definitiva por infrações praticadas antes desta em julgamento. Assim, uma delas será valorada, mais à frente, como reincidência; as demais, ora o são como maus antecedentes.

iii) Na análise da conduta social, consoante a já clássica lição de Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 791), deve-se examinar "o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc." Assim, não se pode confundir os antecedentes sociais da parte ré com os seus antecedentes criminais, de modo que se acabe valorando esses últimos nesta sede (STJ, 5ª Turma, HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2018, DJe. 19/12/2018; e STJ, 6ª Turma, REsp 1.760.972/MG, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/2018, DJe. 04/12/2018)

Nada há nos autos que desabone a conduta social da parte ré. Assim, sua conduta social deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

iv) Na análise da personalidade do agente, "entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo" (idem, p. 790), deve-se examinar a sua índole e caráter. Este exame deve-se pautar em elementos concretos, sendo insuficiente, para fins de justificação de eventual valoração negativa, a simples menção a uma "personalidade criminosa" (STJ, 6ª Turma, HC 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015, DJe. 11/12/2015)

Não há nos autos elementos concretos que permitam aferir conclusivamente a personalidade da parte ré. Assim, sua personalidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

v) Na análise dos motivos do crime, entendidos como "a fonte propulsora da vontade criminosa" (idem, p. 791), deve-se examinar a natureza e a qualidade dos motivos, ou, na lição de Hungria, citada por Bittencourt (idem, ibidem), se são morais/imorais ou sociais/antissociais.

Os motivos que levaram a parte ré a cometer o delito não fogem daquilo que é comum nos crimes deste jaez. Assim, os motivos devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

vi) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt (idem, ibidem), as circunstâncias "defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objetos, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes", devendo-se cuidar que "determinadas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime ou, de alguma forma, são valoradas em outros dispositivos, ou até mesmo como elementares do crime", hipóteses em que deverão ser examinadas em outro momento. As circunstâncias em que se deu o crime já estão abrangidas pelo tipo penal. Assim, as circunstâncias do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

vii) Na análise das consequências do crime, deve-se ter em vista que essas não se confundem com o resultado natural ou jurídico do crime. Mais uma vez, na lição de Bittencourt (idem, p. 792), cabe "analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime." Não se constata que o crime tenha gerado danosidade que já não esteja abrangida pelo tipo, nem há notícia de alarma social. Assim, as consequências do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

viii) O crime em questão é classificado doutrinariamente como delito vago, isto é, conquanto o Estado seja considerado uma vítima indireta, não há nenhuma vítima direta definida, razão pela qual não se cogita do comportamento da vítima para a produção do resultado delitivo.

Para a valoração das circunstâncias judiciais negativas, utilizo a fração de 1/8, filiando-me ao recente precedente do STJ:

"4. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a

jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

5. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

(AgRg nos EDcl no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)"

Havendo duas circunstâncias judiciais negativas, a pena-base fica fixada no mínimo legal, isto é 6 anos, 3 meses e 625 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que:

i) Incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

ii) Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP).

Em que pese a incidência das circunstâncias atenuantes, deixa-se de minorar a pena, pois na segunda-fase não se permite a fixação de pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231-STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".)

Quando presentes, simultaneamente, agravantes e atenuantes genéricas, a regra é a compensação de umas com as outras (regra da equivalência das circunstâncias), ressalvados os casos em que presentes as chamadas circunstâncias preponderantes. Segundo o art. 67 do CP, entende-se como circunstâncias preponderantes as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Tendo isso em vista, veja-se.

No presente caso, verifica-se que a parte ré é multirreincidente e reincidente específica no delito de tráfico de drogas, mas confessou o crime, a revelar traço de sua personalidade que indica arrependimento e desejo de emenda. Em que pese tratarem-se, a reincidência e a confissão espontânea, de circunstâncias preponderantes, a pacífica jurisprudência do STJ é pela possibilidade da compensação (STJ, 3ª Seção, EREsp 1.154.752/Rs, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23/05/2012). Contudo, nos casos em que presente o fenômeno da multirreincidência, ainda que o réu confesse, não se admite a compensação, pois isto implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Com efeito, não se pode admitir que seja aplicada à parte ré multirreincidente reprimenda igual a daquela que ostenta contra si apenas uma condenação definitiva por fato isolado em sua vida (STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 08/09/2020). Desta feita, deixa-se de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, preponderando a primeira em detrimento da última.

Para a valoração das agravantes e das atenuantes, valho-me da fração de 1/6 (STF - HC: 69392 SP, Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/1992, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 12-03-1993 PP-03560 EMENT VOL-01695-03 PP-00610).

Não havendo quaisquer circunstâncias atenuantes a serem aplicadas, mas presente a agravante da reincidência, a pena-base deve ser majorada. Assim, a pena-intermediária fica fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, tem-se que:

i) Não incidem quaisquer causas de aumento da pena.

ii) Não incidem quaisquer causas de diminuição da pena.

Não incidentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição, a pena fica finalmente arbitrada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa

Valor do Dia-Multa

Fixo o valor da dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), uma vez que não há nos autos dados suficientes à análise exauriente da situação econômica da parte ré (art. 60, caput, do CP).

Detração

Deixo de efetuar a detração (art. 42 do CP), como manda o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes informações suficientes sobre imposição e cumprimento de penas privativas de liberdade por outros crimes (art. 111 da LEP).

Regime Inicial de Cumprimento

Dispõe o art. 33 do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

- a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
- b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
- c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

- a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
- b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
- c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir da aferição de quatro critérios: tipo de pena prevista para o tipo legal (reclusão ou detenção), quantidade de pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais (art. 33, §§2º e 3º, do CPP), sendo certo que a imposição de regime mais severo do que o permitido pela pena aplicada exige motivação idônea (Súmula 719-STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea"), exigência essa não satisfeita pela mera menção à gravidade em abstrato do crime (Súmula 718-STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada").

No presente caso, tem-se que:

- i) a pena ficou definitivamente fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão ;
- ii) a parte ré é reincidente específica;
- iii) as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Portanto, entende-se como correto o estabelecimento do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.

Observe-se que o reconhecimento do tráfico privilegiado afasta a hediondez do crime. Todavia, ainda que assim não fosse, desde há muito que se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos (STF, Plenário, HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/06/2012).

Dispõe o art. 44 do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

- I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;
- II - o réu não for reincidente em crime doloso;
- III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição

seja suficiente.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos depende do preenchimento de requisitos objetivos (natureza do crime e quantidade de pena aplicada) e subjetivos (não ser reincidente em crime doloso, observada a exceção da recomendação social da medida, e ser suficiente a substituição).

No presente caso, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Neste ponto, aliás, cumpre rememorar que, reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistiu óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (HC 482234/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/06/2019, DJe 14/06/2019; AgRg no REsp 1777922/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Suspensão Condicional da Pena (Sursi)

Dispõe o art. 77 do CP:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena depende do preenchimento de requisitos objetivos (natureza e quantidade da pena privativa de liberdade e sua não substituição por restritiva de direitos) e subjetivos (não ser reincidente em crime doloso e parcela das circunstâncias judiciais favoráveis).

No presente caso, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 2 (dois) anos.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade da concessão da suspensão condicional da pena.

IV- DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o Sr. Lukas Ricardo Furayama Zadi qualificado à fl. 15, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, com o dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser inicialmente cumprida em regime fechado. Isso por considerar a parte ré como incurso no art. 33,

caput, da Lei 11.343/06

V - COMUNICAÇÕES FINAIS

Em atenção ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, observe-se que a parte ré respondeu a este processo presa, nada tendo sobrevivendo no curso do processo a alterar o juízo sobre a necessidade da imposição de sua prisão preventiva. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado. Recomende-se, portanto, o réu preso no estabelecimento em que se encontra.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/2003). Neste ponto, observo que não há lacuna no CPP, a atrair a incidência do CPC/15, notadamente dos dispositivos que ali tratam sobre a gratuidade de justiça. Quisesse o legislador isentar o acusado pobre das custas nos crimes de ação penal pública, teria o feito, como de fato o fez no art. 806, §1º, do CPP. Nem se diga que o art. 806, §1º aplica-se à hipótese, pois, como se sabe, o parágrafo excepciona a regra do caput (art. 11, inc. III, alínea "c", da LC 95/98).

Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita, em se tratando de ação penal pública, cabe ao Juízo da Execução Penal (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; e AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 04/02/2020, DJe 27/02/2020), sendo certo que a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça não exclui a possibilidade de condenação do acusado ao pagamento de custas processuais, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Ryenaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; e AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 11/04/2019, DJe 30/04/2019).

Determino o perdimento do numerário apreendido em favor da União (art. 63, inc. I e art. 62-A, §3º, da Lei 11.343/06).

Proceda-se em relação às drogas na forma do art. 72 da Lei 11.343/06, acaso não se tenha procedido na forma dos arts. 50 e 50-A do mesmo diploma legal.

Transitado em julgado: (i) proceda-se à atualização do valor da multa, intimando-se o réu para pagamento em 10 dias, nos termos dos arts. 49, §2º, 50 e 51 do CP e 164 da LEP; (ii) oficie-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III, da CF/88; (iii) oficie-se o IIRGD.

Expeça-se Certidão de Honorários Advocatícios, nos termos do Convênio DPE/OAB, se for o caso.

Sentença registrada eletronicamente. Publicada em Audiência. Saíram os presentes intimados.

Ilha Solteira, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA